

УДК 346.26 (477)

Кульгавець Христина Юріївна –

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри права,
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Khrystyna Yu. Kulhavets –

candidate of juridical sciences, Senior Lecturer
at the law department of the
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies of Lviv (50 Pekarska Street, Lviv, 79010, Ukraine)

Ніканорова Олена Володимирівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права,
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Olena V. Nikanorova –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor at the law department of the
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies of Lviv
(50 Pekarska Street, Lviv, 79010, Ukraine)

Особливості правового регулювання договору про закупівлю

Стаття присвячена аналізу положень щодо особливостей правового регулювання одного із різновидів господарських договорів – договору про закупівлю. Зазначається, що у світлі вдосконалення процедури публічних закупівель шляхом уведення законодавчих новел набуває актуалізації значення договору про закупівлю. Розкриваються вимоги щодо істотних умов, форми, способи забезпечення виконання, наслідки невиконання чи неналежного виконання договору про закупівлю.

Ключові слова: господарський договір, публічні закупівлі, договір про закупівлю, істотні умови договору про закупівлю.

Статья посвящена анализу правовых норм одного из видов хозяйственных договоров – договора о закупке. Отмечено, что, учитывая упорядочения процедуры публичных закупок путем внесения изменений в законодательство, приобретает актуальность значение договора в этой сфере. Раскрыто требования относительно существенных условий, форм, способов обеспечения исполнения, последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о закупке.

Ключевые слова: хозяйственный договор, публичные закупки, договор о закупке, существенные условия договора о закупке.

Kh.Yu. Kulhavets, O.V. Nikanorova Features of Legal Regulation of Procurement Contract

The article analyzes the provisions on the peculiarities of the legal regulation of one of the types of business contracts – the purchase contract. It is noted that in light of the improvement of the public procurement procedure by introducing legislative amendments, the value of the procurement contract is updated. Requirements regarding essential conditions, form, enforcement, consequences of non-performance or improper performance of the procurement contract are disclosed.

A key feature of a procurement contract is its conclusion as a result of the procurement procedure, that is, a contract concluded outside such a procedure does not belong to a procurement contract within the meaning of the Public Procurement Law. In addition, a contract under which the customer does not receive ownership of the product or that no services or work are not provided to the customer cannot also be considered a purchase contract.

The Law on Public Procurement establishes only the peculiarities of certain contractual relations, the provisions of this law are special rules that determine the legal grounds for amendments and additions to contracts concluded as a result of public procurement. In doing so, the contract must comply with all the formal requirements of the Civil and Commercial Codes. It is worth noting that often special rules do not supplement but contradict general norms.

In order to properly develop the terms of the procurement contract, you must follow the following rules: correctly define the subject of the contract and its subjects; adhere to procurement principles; it is necessary to evaluate the current consequences of force majeure, especially during the period of hostilities; not to violate clearly established legal rules.

Keywords: economic contract, public procurement, procurement contract, essential terms of the procurement contract.

Постановка проблеми. Загальний порядок оформлення і укладення договору про закупівлю передбачений загальними положеннями Цивільного та Господарського кодексів. Разом з тим, правові підстави внесення змін та доповнень до договорів, укладених за наслідком публічних закупівель визначають норми спеціального законодавчого акту – Закону України «Про публічні закупівлі», нова редакція якого набуває чинності 19.04.2020 р., і увага громадськості, суб'єктів господарських відносин до якого тільки зростає.

Відтак виникає потреба щодо подальшого вивчення положень нормативно-правових актів, які регламентують договірні відносини публічних закупівель.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стаття ґрунтується здебільшого на аналізі законодавчих актів та висновків судової практики у сфері договірних відносин публічних закупівель. Водночас у роботі залучено доробки Я. Дубової. Цінним у процесі підготовки нашої публікації є дослідження С. Вавженчука, викладене у науковій статті, присвяченій критичному огляду основних проблем укладення договорів про публічні закупівлі у розрізі становлення та динаміки законодавства про публічні закупівлі.

Невирішені раніше проблеми пов'язані з допущенням типових помилок при пануванні закупівель, зокрема недотримання порядку визначення предмета закупівлі у договорі.

Мета статті полягає в аналізі правових норм, які регламентують процедуру укладання та

виконання договору про закупівлю, а також виявлення основних проблем у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Укладення договору про закупівлю є кінцевою метою учасників процедури публічних закупівель. Дефініцію поняття «договору про закупівлю» містить Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» [1] (далі – Закон про публічні закупівлі). Відтак, відповідно до ст. 1 цього закону, *договіром про закупівлю* є договір, який замовник та учасник уклали за результатами процедури закупівлі і який передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

Зважаючи на легальне визначення, ключовою ознакою договору про закупівлю є його укладення внаслідок процедури закупівель, тобто договір, укладений поза такою процедурою, не належить до договору про закупівлю у розумінні Закону про публічні закупівлі. Окрім того, договір, відповідно до якого замовник не отримує права власності на товар, або замовнику не надаються послуги чи не виконуються роботи, також не може вважатися договором про закупівлю.

Закон про публічні закупівлі (п. 1 ст. 36) встановлює лише особливості певних договірних відносин, положення цього закону є спеціальними нормами, які визначають правові підстави внесення змін та доповнень до договорів, укладених за наслідком публічних закупівель. При цьому договір повинен відповідати всім формальним вимогам Цивільного та Господарського кодексів. Варто

зауважити, що часто спеціальні норми не доповнюють, а суперечать загальним нормам.

За загальним правилом (абз. 1 ч. 1 ст. 638 ЦКУ; ч. 2 ст. 180 ГКУ) договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди щодо усіх його істотних (обов'язкових) умов, які становлять зміст договору. *Істотними* є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів конкретного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. Згідно із ст. 638 ЦКУ, до істотних умов належать: 1) умови про предмет договору; 2) умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду; 3) всі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнута згода [2]. Сторони договору про закупівлю досягають згоди через проведення законодавчо описаної процедури закупівлі. Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 180 ГКУ, при укладенні господарського договору сторони – суб'єкти господарювання (визначені ст. 55 ГКУ) і негосподарюючі суб'єкти (юридичні особи, що створені органами державної влади та місцевого самоврядування), між якими виникають господарсько-договірні зобов'язання, повинні у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору [3].

З огляду на те, що істотні умови договору про закупівлю практично не відрізняються від договорів, укладених поза процедурами закупівель, і оскільки Законом про публічні закупівлі не передбачено інших спеціальних умов, то предмет, ціна та строк належать до обов'язкових умов договорів про закупівлю.

Що стосується формулювання *предмета* договору закупівлі, замовнику слід чітко визначити – товар, послуги чи роботи він закуповуватиме. До того ж, зважаючи на ч. 4 ст. 180 ГК, у договорі закупівлі повинно бути зазначено найменування (номенклатура, асортимент), кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги щодо їх якості.

Ціна договору про закупівлю – це ціна товару, роботи чи послуги, запропонована учасником (переможцем) процедури закупівлі за результатами електронного аукціону. Норма ст. 36 Закону про публічні закупівлі передбачає можливість зміни ціни договору про закупівлю, а точніше – збільшення ціни до 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку. Йдеться

про те, що сторони вправі укласти додаткову угоду про збільшення ціни договору (в розмірі не більше ніж на 10%). Щоправда, зазначена зміна не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі. Однак збільшення ціни договору потягне за собою зменшення інших витрат шляхом скорочення кількості поставок. Варто звернути увагу на те, що ця норма передбачена для застосування з операціями, пов'язаними виключно із закупівлею товару, і не стосується закупівлі робіт та послуг.

З огляду на ч. 7 ст. 180 ГКУ, *строком* дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов'язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору [3].

Спеціальні граничні *строки* для укладення договорів про закупівлю прямо залежать від процедури, яку замовник застосував для відбору постачальника товару, надавача послуги та виконавця робіт для укладення договору. При відкритих торгах/конкурентному діалозі договір про закупівлю укладають: 1) не раніше ніж через 10 календарних днів з дня опублікування повідомлення про намір укласти договір; 2) не пізніше 20 календарних днів з дня визначення переможця; 3) не раніше ніж через 10 календарних днів з дня опублікування повідомлення про намір укласти договір [1].

При проведенні переговорної процедури договір про закупівлю укладають: 1) не пізніше 35 днів з дня опублікування повідомлення про намір укласти договір; 2) не пізніше 20 днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 35 Закону про закупівлі; 3) у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого

водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування [1].

Крім того, п. 4 ст. 36 Закону про публічні закупівлі встановлює, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, якщо [1]:

- потрібно зменшити обсяги закупівлі через фактичний обсяг видатків замовника;

- відбулось коливання ціни товару на ринку – змінюють ціну за одиницю товару не більше ніж на 10%, але без збільшення суми, визначеної в договорі (про що описувалось вище);

- якість предмета закупівлі покращується, але за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Приміром, якщо контрагент не може поставити товар такої якості як зазначена в договорі, він може поставити інший товар кращої якості, але без підвищення його ціни.

- є документально підтверджені об'єктивні обставини, спричинені непереборною силою, затримкою фінансування витрат замовника тощо – продовжується строк дії договору та виконання зобов'язань без збільшення суми, визначеної в договорі;

- сторони узгодили зміну ціни в бік зменшення без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг;

- змінено ставки податків і зборів – змінюють ціну пропорційно до змін таких ставок;

- змінено індекс споживчих цін, курс іноземної валюти, біржові котирування або показники Platts, регульовані ціни (тарифи) і нормативи, які застосовуються в договорі про закупівлю, і в ньому передбачено порядок зміни ціни;

- є підстави продовжити строк дії договору згідно з ч. 5 ст. 36 Закону про публічні закупівлі. Тобто дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році.

Таким чином, сторони за договором про закупівлю можуть внести зміни до його істотних умов тільки у зазначених вище випадках,

керуючись нормами ЦК, ГК і Закону про публічні закупівлі. Разом з тим, необхідно пам'ятати про переваги норм спеціального закону. Це, зокрема, підтверджується постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.01.2018 р. у справі № 916/1491/17 [4]. Суд в нагадав, що норми Закону про публічні закупівлі є спеціальними нормами, які визначають правові підстави внесення змін та доповнень до договорів, укладених за наслідком публічних закупівель, різновидом яких є тендерні закупівлі, та повинні застосовуватися переважно щодо норм ЦК України (ст. 651) та ГК України (ст. 188), які визначають загальну процедуру внесення змін до договору. Відтак, якщо спеціальною нормою права (ч. 4 ст. 36 Закону про публічні закупівлі) заборонено укладення умов договору про публічні закупівлі, які відрізняються від умов тендерної пропозиції, та заборонено вносити зміни до договору, окрім певного переліку таких змін, то внесення змін до такого договору поза межами цього переліку, означатиме нікчемність таких змін до договору відповідно. Тобто такі зміни не зможуть породжувати передбачені правові наслідки.

З огляду на вказану постанову, замовнику слід передбачити у договорі ймовірність такої зміни істотних умов з тим розрахунком аби не допустити їх скасування в судовому порядку.

Що стосується *форми* договорів про закупівлю, то Закон про публічні закупівлі не містить вимоги лише їх письмового оформлення, натомість пряма вказівка на положення ЦК і ГК передбачає можливість застосування норм цих кодифікованих актів. Нагадаємо, ст. 205 ЦК визначає, що правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Як бачимо, відповідно до положень ЦК, який передбачає можливість укладення договорів в електронній формі, замовник і переможець торгів можуть укладати договори про закупівлю в електронній формі, якщо мають для цього відповідні технічні та організаційно-правові передумови.

Договір вважається укладеним з моменту:

- 1) надання йому тієї форми, про яку сторони домовилися, навіть коли законом ця форма для такого виду договорів не вимагалася (ч. 2 ст. 639 ЦК);
- 2) якщо сторони домовилися про

нотаріальне посвідчення договору, щодо якого законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення (ч. 4 ст. 639 ЦК); 3) одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (ч. 1 ст. 640 ЦК). А договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення.

Ч. 2 ст. 31 Закону про публічні закупівлі передбачено, що замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Тож фактично проект договору в тендерній документації – це і є майбутній договір про закупівлю. При цьому учасник процедури закупівлі має погодитися з таким проектом договору, адже при його укладенні сторони не зможуть відступити від положень, прописаних у тендерній документації (проекті договору). За таких умов замовникам слід вимагати від учасників надання в тендерній пропозиції підтвердження згоди (можна в довільній формі, а можна і за формою, визначеною в тендерній документації) з проектом договору.

При цьому Мінекономрозвитку в листі від 30.12.2016 р. № 3302-06/42560-06 «Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю» [5] звертає увагу на те, що в разі незгоди учасника з умовами тендерної документації на підставі положень Закону про публічні закупівлі він має право звернутися до замовника за роз'ясненнями, з вимогою про усунення порушень (якщо такі існують, на думку учасника). Також ніхто не забороняє учаснику оскаржити відповідні положення тендерної документації, зокрема у частині проекту договору, якщо такі положення порушують його права та законні інтереси.

Принагідно зауважимо, що висування вимоги про нотаріальне посвідчення договору про закупівлі є правом, а не обов'язком замовника.

Відповідно до ч. 2 статті 32 Закону України про публічні закупівлі, замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії

його пропозиції, відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

Дуже часто укладення договору про закупівлю – лише половина справи, оскільки складно передбачити належне виконання учасником взятих договірних зобов'язань без порушення умов. Таке порушення, своєю чергою, потягне заподіяння державі збитків у вигляді недоотримання коштів. У такому разі уникнути ризиків з недобросовісними учасниками допоможе *забезпечення виконання* договору про закупівлю.

Замовник вправі вільно обирати будь-який вид забезпечення виконання зобов'язань передбачених законодавством (неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток тощо).

Розглянемо найбільш відповідні види забезпечення за договором про закупівлю.

Замовник може вимагати від переможця надати забезпечення виконання зобов'язань за договором у вигляді *гарантії* від банку, іншої фінансової установи або страхової компанії. Зазвичай, на момент укладання договору у переможця не виникає перешкод, аби виконати цю вимогу і надати замовнику гарантію. Однак, закупівельна практика підтверджує певні труднощі для замовників, коли у разі гарантійних випадків вони звертаються до гаранта за виплатою суми забезпечення. До прикладу, буває, що банк, до якого звертається замовник за стягненням коштів за гарантією, подає до суду позов про визнання недійсним договору про забезпечення. І тоді замовнику не уникнути судової тяганини [6].

Іншим випадком є звернення замовника до банку для виплати коштів за гарантією у час, коли банк вже не мав ліцензії на провадження банківської діяльності і перебував у стані ліквідації. З метою захисту своїх прав, замовник має звертатися до банку у процесі його ліквідації в порядку, встановленому Законом України від 23.02.2012 р. № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [7]. Цей закон регламентує, зокрема, проведення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Для того, щоб отримати забезпечення за банківською гарантією, замовник обов'язково повинен документально підтвердити вину контрагента у невиконанні договірних

зобов'язань, встановлених умовами договору. в протилежному випадку – якщо умови договору не виконані через дії самого замовника і вини контрагента у невиконаних зобов'язаннях немає, то замовник не отримає забезпечення виконання договору.

Ще одним із видів забезпечення за договором про закупівлю є *застава*. Ст. 572 ЦК встановлює, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставадавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлює закон (право застави) [2].

Предметом застави може бути будь-яке майно або грошові кошти. Виняток становлять культурні цінності, що є об'єктами права державної чи комунальної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання; а також пам'ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Замовник вправі передбачити заставу в тендерній документації у вигляді майнових прав на грошові кошти, які можуть перераховуватись на казначейський рахунок (якщо замовник – бюджетна установа) або на рахунок замовника в банку (якщо замовник – державне підприємство). На практиці такий забезпечення є зручнішим для замовника, адже стягнути таке забезпечення простіше, ніж забезпечення у вигляді гарантії.

Окрім того, замовники можуть встановлювати вимогу щодо забезпечення виконання договору у вигляді *депозиту* (банківського вкладу). Разом з тим, не варто обирати депозит як забезпечення виконання договору замовникам, рахунки яких обслуговує Казначейство. Адже воно не виплачуватиме відсотки за депозитом, а без них не можна вважати, що цей вид забезпечення оформлений за вимогами законодавства.

Варто пам'ятати, що розмір забезпечення виконання договору про закупівлю *не може перевищувати 5%* вартості договору. До того ж, у тендерній документації необхідно вказати умови надання забезпечення виконання договору, яких має дотримати учасник-переможець (розмір; вид; строк та умови надання; умови повернення та неповернення

забезпечення виконання договору про закупівлю). Окрім того, учаснику-переможцю необхідно внести забезпечення виконання договору *не пізніше дати укладення* договору про закупівлю.

Замовник зобов'язаний повернути забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше ніж протягом *п'яти банківських днів* з дня, коли настали такі обставини: після того, як учасник-переможець виконає договір; якщо суд визнає результати процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними; якщо договір про закупівлю є нікчемним згідно з ст. 37 Закону про публічні закупівлі; якщо настали інші умови, передбачені в договорі.

Договір про закупівлю є *нікчемним*, коли його недійсність встановлює закон. Відповідно до ст. 37 Закону про публічні закупівлі, нікчемним вважають договір, якщо його [1]:

- умови відрізняються від змісту тендерної пропозиції учасника торгів, а за переговорної процедури – від ціни пропозиції, або істотні умови змінені без врахування вимог статті 36 Закону про публічні закупівлі;

- уклали в період оскарження процедури закупівлі;

- уклали з порушенням строків – раніше ніж через 10 днів із дати оприлюднення на ProZorro повідомлення про намір укласти договір про закупівлю та пізніше ніж через 20 днів із дня прийняття рішення про намір укласти договір, а також строків, встановлених для укладення договору за результатами переговорної процедури. Якщо, звичайно, не йдеться про випадки, коли перебіг строків зупиняється через розгляд скарги органом оскарження.

Як відомо, недійсний правочин не створює юридичних наслідків (ч. 1 ст. 216 ЦК). Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 651 ЦК, ч. 1 ст. 188 ГК). Якщо сторони змінюють договір, то зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо (ч. 1 ст. 653 ЦК).

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором (ч. 2 ст. 188 ГК). Своєю чергою, сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 20-денний строк

після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду (ч. 3 ст. 188 ГК).

Отже, якщо сторони передбачили в договорі про закупівлю право замовника в *односторонньому порядку* розривати його, то замовник може реалізувати це право. Навіть якщо контрагент не згодний внести зміни про зменшення загальної суми договору з 5 млн грн на 200 тис. грн через зменшення фактичних видатків. При цьому змінювати або розривати договір треба в такій самій формі, в якій він був укладений, якщо інше не встановлено договором або законом чи не впливає із звичаїв ділового обороту (ч. 1 ст. 654 ЦК).

Разом з тим, якщо в договорі не закріплено право замовника в односторонньому порядку розривати договір про закупівлю, або якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору, або у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу не одержано відповіді, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду (ч. 4 ст. 188 ГК). У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються (ч. 2 ст. 653 ЦК). Якщо договір змінили або розірвали, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінили або розірвали через суд, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду законної сили (ч. 3 ст. 653 ЦК).

За таких обставин замовникам та учасникам важливо врахувати висновки господарських судів [8, 9].

Водночас, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні належно виконувати господарські зобов'язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставлять (ч. 1 ст. 193 ГК). При цьому кожна сторона повинна вжити всіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій,

передбачених ГК, іншими законами або договором (ч. 2 ст. 193 ГК).

Відповідно до ч. 1 ст. 224 ГКУ, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Наприклад, буває в договорі про закупівлю передбачають, що відповідальність сторін за невиконання умов договору встановлюється згідно з чинним законодавством. На жаль, на практиці прописана умова про відповідальність виявляється декларативною, яка ні до чого не зобов'язує контрагента за договором. Тож для того, щоб в майбутньому не відстоювати в судових інстанціях право на отримання відшкодування збитків, необхідно в договорах про закупівлю погоджувати таку умову, як відповідальність сторін за невиконання договірних зобов'язань, зокрема, щодо відшкодування збитків, сплати штрафних санкцій.

Згідно з ч. 2 ст. 224 ГКУ під *збитками* розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або дотримання правил здійснення господарської діяльності другою стороною. Сторони господарського зобов'язання мають право за взаємною згодою заздалегідь визначити погоджений розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, у твердій сумі або у вигляді відсоткових ставок залежно від обсягу невиконання зобов'язання чи строків порушення зобов'язання сторонами. При цьому зауважимо: не допускається погодження між сторонами зобов'язання щодо обмеження їх відповідальності, якщо розмір відповідальності для певного виду зобов'язань визначений законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 229 ГКУ, учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов'язання не звільняється від відповідальності через неможливість виконання і зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням зобов'язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановлених ГКУ та іншими законами. Як бачимо, одночасно із відшкодуванням збитків

учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання чи правила здійснення господарської діяльності, має сплатити стороні, права якої порушені, штрафні санкції. При цьому відповідальність за завдані збитки виконує компенсаційну функцію. Одночасно через відповідальність у вигляді штрафних санкцій реалізується караюча функція у сфері господарювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГКУ, штрафні санкції – це господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. Варто зазначити, що законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається:

В разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектору економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, то штрафні санкції застосовують, якщо інше не передбачено законом чи договором, у *таких розмірах* [3]:

- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);

- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

Слід зазначити, що згідно з ч. 6 ст. 231 ГКУ штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Як передбачено ст.ст 1, 3 Закону України від 22.11.1996 р. № 543 «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», розмір пені, встановлений за згодою сторін, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійну облікову ставку НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня [10]. Як бачимо, чинне законодавство обмежує розмір пені за грошовими зобов'язаннями. І що важливо – платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочення платежу саме пеню. Що стосується питання можливості стягнення штрафу, а не пені за грошовими зобов'язаннями в господарських відносинах, то воно є спірним на практиці. Тому цей момент необхідно враховувати замовникам, передбачаючи умови відповідальності в договорі про закупівлю.

Варто також нагадати: відповідно до положень ч. 6 ст. 232 ГКУ нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через 6 місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. У зв'язку з цим, строк, за який нараховуються штрафні санкції, і позовна давність для пред'явлення вимог про стягнення штрафних санкцій – це різні речі. Так, щодо вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) відповідно до ч. 2 ст. 258 ЦКУ передбачено спеціальну (скорочену) позовну давність – один рік.

Отже, як бачимо, хоча умова щодо відповідальності за невиконання договору і не є однією з істотних умов договору, через непогодження якої договір може вважатися неукладеним, проте замовнику слід дуже уважно підходити до прописування ще в проекті договору та, відповідно, в тендерній документації положень щодо відповідальності сторін договору. Тому погоджуючись з проектом договору в тендерній пропозиції, учасник таким чином погоджується з тією мірою відповідальності, яку він нестиме в разі виграшу в торгах та укладення з ним договору про закупівлю.

До суду може звернутися й контрагент. Якщо контрагент добросовісно виконує договір та не бажає вносити до нього зміни, то йому доцільно звернутися до суду за захистом своїх

прав і законних інтересів у частині відшкодування замовником *упущеної вигоди*.

У вигляді упущеної вигоди відшкодовують доходи, які контрагент міг би реально отримати. Пред'явлення до замовника вимоги про відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на кредитора (контрагента) обов'язок довести, що ці доходи (вигода) не є абстрактними, а дійсно були б ним отримані, якби замовник належно виконав свої договірні зобов'язання. Контрагент у суді має підтвердити не лише розрахунок розміру упущеної вигоди, а й обґрунтувати та довести реальну можливість її отримання. Тобто мають бути всі *елементи складу цивільного правопорушення*: протиправна поведінка замовника, яка виявляється у невиконанні або неналежному виконанні ним зобов'язання; наявність (реальність) збитків (упущеної вигоди); причинний зв'язок між протиправною поведінкою і завданими збитками (упущеною вигодою): збитки є наслідком порушення боржником (замовником) зобов'язання, а не інших обставин, зокрема дій кредитора (контрагента), третіх осіб; вина замовника.

Висновки. На підставі написаного, висновуємо, що договір про закупівлю оформлюється і укладається відповідно до загальних положень Цивільного та Господарського кодексів з урахуванням спеціальних норм, які визначають правові підстави внесення змін та доповнень до договорів, укладених за наслідком публічних закупівель.

Для того, щоб вірно розробити умови договору про закупівлю, необхідно дотриматись таких правил:

- правильно визначити предмет договору та його суб'єктів;
- дотримуватись принципів закупівель;
- належно оцінити актуальні на сьогодні наслідки форс-мажору, особливо в період проведення військових дій;
- не порушувати чітко встановлених правових норм.

Список використаних джерел:

1. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 груд. 2015 р. № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19> (дата звернення 10.10.2019).
2. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 10.10.2019).
3. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення 20.10.2019).
4. Про зобов'язання внести зміни до укладеного договору про надання послуг з оперативного лізингу автотранспорту: Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30 січ. 2018 р. у справі № 916/1491/17. URL: <http://www.document.org.ua/pro-zobovjazannja-vnesti-zmini-do-ukladenogo-dogovoru-pro-na-doc349121.html> (дата звернення 25.10.2019).
5. Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю: Лист Мінекономрозвитку від 30 груд. 2016 р. № 3302-06/42560-06. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME161574.html (дата звернення 25.03.2019).
6. Дубова Я. Забезпечення виконання договору: як, коли і скільки. *Електронний журнал «Держзакупівлі»*. 2019. № 3. URL: <http://m.edz.mcfra.ua/714090> (дата звернення 25.03.2019).
7. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лют. 2012 р. № 4452-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17> (дата звернення 25.03.2019).
8. Справа № 922/1458/17 про скасування рішення тендерного комітету КП «Харківводоканал», оформленого протоколом № 21/14 від 28 квіт. 2017 р.: Рішення Господарського суду Харківської області від 22 трав. 2017 р. URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/66657526/> (дата звернення 26.03.2019).
9. Справа № 906/424/18 про визнання недійсним рішення тендерного комітету, оформленого протоколом № 58 від 22 січ. 2018 р.: Рішення Господарського суду Житомирської області від

13 верес. 2018 р. URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/76608506/> (дата звернення 26.03.2019).

10. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22 лист. 1996 р. № 543. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-вр> (дата звернення 26.03.2019).

References:

1. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy vid 25 hrud. 2015 r. № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19> (data zvernennia 10.10.2019).

2. Tsyvilnyy kodeks Ukraïny vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia 10.10.2019).

3. Hospodarskyi kodeks Ukraïny vid 16 sich. 2003 r. № 436-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (data zvernennia 20.10.2019).

4. Pro zobov'iazannia vnesty zminy do ukladenooho dohovoru pro nadannia posluh z operatyvnoho lizynhu avtotransportu: Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 30 sich. 2018 r. u spravi № 916/1491/17. URL: <http://www.document.org.ua/pro-zobovjazannja-vnesti-zmini-do-ukladenogo-dogovoru-pro-na-doc349121.html> (data zvernennia 25.10.2019).

5. Shchodo ukladennia, vykonannia, zminy ta rozirvannia dohovoru pro zakupivliu: Lyst Minekonomrozvytku vid 30 hrud. 2016 r. № 3302-06/42560-06. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME161574.html (data zvernennia 25.03.2019).

6. Dubova Ya. Zabezpechennia vykonannia dohovoru: yak, koly i skilky. *Elektronnyi zhurnal "Derzhzakupivli"*. 2019. № 3. URL: <http://m.edz.mcfra.ua/714090> (data zvernennia 25.03.2019).

7. Pro systemu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib: Zakon Ukrainy vid 23 liut. 2012 r. № 4452-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17> (data zvernennia 25.03.2019).

8. Sprava № 922/1458/17 pro skasuvannia rishennia tendernoho komitetu KP "Kharkivvodokanal", oformlenoho protokolom № 21/14 vid 28 kvit. 2017 r.: Rishennia Hospodarskoho sudu Kharkivskoi oblasti vid 22 trav. 2017 r. URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/66657526/> (data zvernennia 26.03.2019).

9. Sprava № 906/424/18 pro vyznannia nediisnym rishennia tendernoho komitetu, oformlenoho protokolom № 58 vid 22 sich. 2018 r.: Rishennia Hospodarskoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 13 veres. 2018 r. URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/76608506/> (data zvernennia 26.03.2019).

10. Pro vidpovidalnist za nesvoiechasne vykonannia hroshovykh zobov'iazan: Zakon Ukrainy vid 22 lyst. 1996 r. № 543. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-вр> (data zvernennia 26.03.2019).